



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC**

DE LA CONCUSIÓN/ LEY 599 DE 2000

El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años¹.

CODIGO DISCIPLINARIO UNICO-Exigencias en deberes del servidor público en el servicio y en el trato no vulneran los principios de tipicidad, legalidad y debido proceso disciplinario

Los numerales 2 y 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, consagran para todos los servidores públicos: un deber general afirmativo relativo al cumplimiento del servicio que le haya sido encomendado con las exigencias de diligencia, eficiencia e imparcialidad; un deber general negativo referido a la abstención de cualquier clase de acto u omisión que origine la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial o el abuso indebido del cargo o de las funciones encomendadas, y una obligación de carácter general de comportarse con respeto, imparcialidad y rectitud en las relaciones interpersonales por razón del servicio público que le haya sido encomendado, deberes y obligaciones que constituyen un desarrollo de las normas constitucionales que son el fundamento de la responsabilidad disciplinaria, sobre los que la Corte encuentra que las expresiones demandadas son fiel desarrollo de mandatos constitucionales y son deberes y obligaciones generales y básicos que están consagrados en la Carta Política o constituyen un desarrollo de postulados de la administración pública y de la responsabilidad disciplinaria; que se encuentran en plena armonía con las finalidades constitucionales propias del derecho disciplinario; que no vulneran en sentido alguno los principios de tipicidad y legalidad rectores del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 Superior, y que no es cierto que estas expresiones constituyan tipos en blanco o conceptos jurídicos indeterminados respecto de los cuales el operador disciplinario no pueda llevar a cabo una remisión normativa o realizar una interpretación sistemática².

FALTA GRAVISIMA EN PROCESO DISCIPLINARIO-Realización de conducta descrita como delito/**FALTA GRAVISIMA EN PROCESO DISCIPLINARIO**-No condicionamiento a trámite de proceso penal

Para la demandante la aplicación del numeral 1º del artículo 48 de la ley 734 de 2002, requiere la participación de una autoridad judicial quien calificaría si la conducta por la cual se ha iniciado el proceso corresponde a un delito. Esta forma de interpretar el precepto demandado no corresponde a lo establecido por el legislador, pues en él quedó previsto que se consideran faltas gravísimas aquellas que atiendan a los siguientes supuestos: i) Que se trate de una conducta objetivamente descrita por la ley como delito; ii) Que la misma conducta punible sea sancionable a título de dolo; y iii) Que la misma conducta se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. Para la Sala es evidente que el Congreso de la República no condicionó la aplicación de la norma sub examine al trámite de un proceso penal y menos aún a la calificación que una autoridad judicial hiciera respecto del comportamiento causante del proceso disciplinario. La disposición atacada obliga al “juez disciplinario” a verificar en la legislación penal si la conducta que ha dado lugar al proceso está descrita objetivamente o tipificada, para posteriormente establecer dentro del proceso a su cargo si la misma conducta fue cometida con dolo o culpa, con el propósito de imponer la respectiva sanción atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único-³.

¹ Artículo 404.

² Sentencia C – 030 de 2012.

³ Sentencia C – 720 de 2006.



POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número del Proceso:	1704-01-2014-131
Número y fecha del fallo:	RESOLUCIÓN No. 17317-00005 del 21 de marzo de 2017
Asunto:	Fallo de primera instancia
Criterio de Selección:	Fallo Sancionatorio

RESOLUCIÓN No. 17317-00005 21 de marzo de 2017

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2014-131, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

IDENTIDAD DEL INVESTIGADO

XXXXX, identificada con C.C. XXXXX, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba en el cargo de GESTOR I CODIGO 301 GRADO 01 en el rol de empleo de PROFESIONAL I PROCESO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION ubicada en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia.

HECHOS

La División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, dentro del expediente L1-2010-2012-000013 adelantó investigación tributaria al señor XXXXX, cuyo objeto era verificar si la información reportada en la declaración de renta y complementaria del año gravable 2010 se ajustaba a la normatividad vigente. Este proceso fue asignado a la funcionaria XXXXX, profesional I del proceso de Fiscalización y Liquidación de esa seccional.

Dentro del desarrollo de sus funciones, el día 23 de agosto de 2012 la funcionaria XXXXX se comunicó telefónicamente con el señor XXXXX, para citarlo a las instalaciones de la DIAN. Consecuentemente y de acuerdo con la llamada telefónica, el día 19 de octubre de 2012 el señor XXXXX se presentó a las instalaciones de la DIAN Leticia, manifestando a la referida funcionaria que no había logrado recuperar los documentos soportes de la contabilidad, ante lo cual la señora XXXXX le ofreció su ayuda, citándolo a un encuentro fuera de la entidad.

En días posteriores, se encontraron en el Parque conocido como "El Brasil", ubicado al lado de la iglesia de Leticia, lugar en el cual conversaron y ante la solicitud de la investigada acordaron que el señor XXXXX le entregaría la suma de dos millones de pesos para "cuadrar" la declaración de renta y evitar la sanción. El acuerdo se concretó en un segundo encuentro en el ysupermercado el "RUKO", en el cual el señor XXXXX, en compañía de su y cónyuge XXXXX, le hicieron entrega de dos millones de pesos a la funcionaria XXXXX.

CARGO FORMULADO

Por medio del Auto No. 17406-00027 del 10 de noviembre de 2016, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la UAE ITRC, formuló pliego de cargos a la investigada XXXXX. El cargo que en ese momento procesal provisionalmente se imputó fue el siguiente:

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

<<(…) CARGO UNICO: La señora XXXXX, identificada con C.C. XXXXX, quien para la fecha de los hechos se desempeñaba en el cargo de gestor I código 301, grado 01, en el rol de empleo de profesional I proceso de fiscalización y liquidación ubicada en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, al parecer, incurrió en la conducta descrita en la Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 1°, en armonía con el artículo 404 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) conducta típica de concusión, en cuanto al parecer solicitó dinero al contribuyente XXXXX para "ayudarlo" en la investigación tributaria que en su contra adelantaba la DIAN bajo el radicado L1-2010-2012- 000013.

Lo anterior, por cuanto el día 19 de octubre de 2012 se reunió en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Leticia con el contribuyente XXXXX, a quien ofreció su ayuda y solicitó "hablar afuera sobre esa situación" (afirmado por el quejoso), para lo cual se citaron en el Parque conocido como "El Brasil".

La reunión en el "Parque El Brasil", ubicado al lado del parque al pie de la iglesia, se efectuó días posteriores. Durante la misma, la señora XXXXX, le solicitó la suma de dos millones de pesos, para favorecer la investigación tributaria, solicitud que se concretó posteriormente con la entrega del dinero en las instalaciones del supermercado "RUKO", tal como se precisara al interior del presente auto (…)>>

De esta manera, el Despacho señaló en el cargo formulado que la descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo realizada objetivamente por la señora CALDERON RUALES, se encontraban establecida en el artículo 404 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal) en los siguientes términos:

<CONCUSIÓN. El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión (…)>

ARGUMENTOS DE DEFENSA:**VERSIÓN LIBRE, DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En diligencia de versión libre y espontánea, la funcionaria XXXXX, arguyó en su defensa lo siguiente: (…)"Las funciones a mi comunicadas como funcionaria de fiscalización son claras y expresas como consta en el expediente, el procedimiento que se sigue en las visitas de campo que se realizan a los contribuyentes son el resultado de mis funciones ya que se por expedientes tributarios, por visitas de facturación o por operativos en aduanas o por cambios, estas visitas se realizan por medio de un auto comisorio que es firmado por la Jefe de la División y es el único acto que nos faculta realizar dichas actuaciones, las decisiones en una actuación no las tomo yo como funcionaria mi único papel es el de sustanciadora, de mis actuaciones rindo un informe que es presentado a la Jefe de la División, quien es la que toma la decisión final, las salidas de campo en ningún momento las realizo sola, siguiendo los principios que nos rige en nuestra institución siempre salidos dos o más personas dependiendo de la actuación a realizar, en la práctica de pruebas administrativas que se programó se pudo constatar de los que aquí menciono y en ningún momento visito ni he visitado a los comerciantes con las intenciones manifestadas por el XXXXX. (…)"

DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSION

La señora XXXXX, fundamentó sus descargos y alegatos de conclusión en cuatro argumentos principales:

Argumentó que la denuncia que originó la actuación disciplinaria fue formulada por una persona al parecer inexistente, pues no de otra manera se explica que hasta la fecha no haya sido posible ubicarla, lo cual es indicativo que se trata de una persona que, a través de una fachada, busca perjudicarla intentando manipular a la familia XXXXX, con el único animo de causarle daño imputándole conductas ilegales que nunca tuvieron ocurrencia.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

Arguyó que el expediente aperturado al señor XXXXX por la declaración de renta del año gravable 2010, es la prueba documental que demuestra que, la acción de auditoria tributaria adelantada por ella, se ajustó a la normatividad tributaria vigente, y por ende se puede concluir que no tuvo interés diferente a establecer la realidad contable y fiscal del contribuyente, agregando que de aceptarse la versión totalmente ajena a la realidad, del señor XXXXX y su familia, el resultado de la auditoria hubiera sido otro, por ende solicitó que esta prueba sea valorada a su favor.

Manifestó que la única prueba que se arrimó a la actuación fue el testimonio "amañado" del señor XXXXX y su familia, los cuales tachó de falsos, pues nunca exigió dádivas por el ejercicio de su cargo, por el contrario, advirtió que las declaraciones rendidas por estas personas, son contradictorias, en cuanto a circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente se desarrollaron los hechos investigados, en tanto no precisaron la hora en que se dio el encuentro, y por el contrario se afirmó por uno de ellos que el hecho se presentó en horas de la mañana por fuera del establecimiento comercial Ruko y el otro afirmó que fue dentro del establecimiento en horas de la tarde.

Refirió que se incurre en otra contradicción, al momento de describir quien fue la persona que supuestamente receiptó el dinero, sumado al hecho que considera más grave y es que ninguno recuerda la fecha en que supuestamente sucedieron los hechos, por lo que concluye que se tratan de afirmaciones falsas, contradictorias y etéreas, afectando la credibilidad del testimonio. Como fundamento de esa afirmación, transcribió apartes de una sentencia sin radicado, que en su contenido señala los requisitos fundamentales de la eficacia del testimonio.

Por último, solicitó dar aplicación a la presunción de inocencia o principio in dubio pro disciplinado, para tal efecto trajo a colación el pronunciamiento de la Corte Constitucional dentro del radicado D-1058.

DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSION DEFENSORA DE XXXXX

Consideró que no se desvirtuó el principio de presunción de inocencia de la señora XXXXX, dado que los medios probatorios recaudados no permiten concluir en grado de certeza la existencia de la falta y la responsabilidad de su defendida, como argumentos principales señaló los siguientes:

En su sentir, las declaraciones en las cuales se soporta la conducta que inculpa a la señora XXXXX se apartan de toda parcialidad, evidenciando una clara contradicción en cuanto a la fecha y hora supuesta de los hechos investigados, por lo que no pueden dar certeza a lo sucedido.

Advirtió que la única prueba que acreditó el encuentro y la entrega de la suma del dinero, son las declaraciones dadas por los familiares del señor XXXXX, quienes claramente tienen un vínculo familiar del cual es evidente el interés de los mismos.

La inspección realizada en las instalaciones y alrededores del supermercado Ruko, no permitió que se probara la ocurrencia de los hechos suscitados, como encuentros y entregas de dinero entre los señores XXXXX, XXXXX y su defendida, por lo cual entra en el plano de la duda.

Con fundamento en los anteriores argumentos solicita se profiera un fallo absolutorio a favor de la señora XXXXX.

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA:**RAZONES DE LA DECISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN QUE SE BASA
MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA:**

Este Despacho es competente para proferir el fallo de primera instancia dentro de la presente investigación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con las previsiones del Decreto 4173 del 3 de noviembre de 2011.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

En atención a lo ordenado en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 ibídem.

De igual manera, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, los cuales es menester se encuentren debidamente acreditados dentro del sumario a partir de elementos de prueba legalmente allegados al proceso.

DEL CASO EN CONCRETO

Establecidas los criterios para la valoración probatoria tenemos que, por ser pertinentes, conducentes y útiles, se decretaron y practicaron en debida forma distintas pruebas para fundamentar la decisión de fondo. Siendo así, como pruebas que acreditan la materialidad de la falta disciplinaria y la responsabilidad, existen las siguientes:

DOCUMENTALES

Respuesta del Subdirector de Gestión de Personal de la DIAN, por medio del cual informan que, en la Dirección Sección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, labora la señora XXXXX, identificada con C.C. XXXXX, en el cargo de GESTOR I CODIGO 301 GRADO 01 en el rol de empleo de PROFESIONAL I PROCESO DE FISCALIZACION Y LIQUIDACION ubicada en la División de Gestión de Fiscalización en dicha seccional.

2. Oficio No. 100206214 0002099 de fecha 25 de julio de 2014, suscrito por la Subdirectora de Gestión de Personal de la Dian, mediante el cual remitió el extracto de la historia laboral con la comunicación de funciones de la señora XXXXX.

Con el anterior documento está plenamente demostrada la vinculación de la señora XXXXX con la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia.

Igualmente se ordenó oficiar a la Coordinación de Historias laborales a fin de establecer si el señor XXXXX, es funcionario de la DIAN, dado que frente a dicha persona también se elevaban varias acusaciones, no obstante, se logró establecer que dicha persona no ha sido vinculada a la planta personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Se realizó diligencia de inspección administrativa en la DIAN de Leticia, el 18 de noviembre de 2014, específicamente en la División de Gestión de Fiscalización y en la División de Gestión de Operación Aduanera de la DIAN Leticia, con el objeto de establecer los contribuyentes que habían sido objeto de auditoria y los tramites de importación adelantados en el primer semestre del año de esa manera se obtuvo planilla en la que se relacionan los 37 expedientes de conocimiento de la funcionaria XXXXX, quien por razón de sus funciones conoce actuaciones de índole tributario especialmente.

Como quiera que el objeto de la diligencia era determinar los nombres de al menos seis contribuyentes y escucharlos en diligencia de testimonio, se realizó una selección aleatoria de las siguientes personas: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX Y XXXXX, aquellas sobre las cuales se realizó consulta en el registro único tributario, con el fin de ubicar su lugar de notificaciones y de esta manera elevar la respectiva citación.

Obra constancia de fecha 5 de noviembre de 2015, en la que se indica lo siguiente: "se deja constancia que los suscritos abogados designados se hicieron presentes en la carrera 7 No. 10-31 de la ciudad de Leticia Amazonas con el fin de ubicar y citar al señor XXXXX, quien funge como quejoso dentro de la presente investigación, se verifico la no existencia de la dirección, de igual manera se indago con los ciudadanos del sector donde se estableció que no reside en zona y lo no conocen".

Anexo a esta constancia se encuentran tres fotografías de la dirección aludida.¹

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

Diligencia de visita administrativa realizada en el Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia a través de la cual se obtuvo copia del expediente radicado L1- 2010-2012-000013 con fecha de apertura 9 de marzo de 2012 contra el contribuyente XXXXX identificado con C.C. XXXXX, expediente que consta de un tomo con un total de 104 folios útiles, el cual es allegado en medio magnético.

De la revisión de dicho expediente se extrae como actuaciones relevantes las siguientes:

Obra formulario del registro único tributario del señor XXXXX identificado con C.C. XXXXX, como propietario de la razón social XXXXX No 1 ubicado en la CR 12 CL 7 ESQ de la ciudad de Leticia.
Declaración de renta año gravable 2009, presentada el 25 de agosto de 2010.
Declaración de renta año gravable 2010, presentada el 10 de agosto de 2011.
Folios 238 a 241

Plan de auditoria en el cual se indica que el objetivo de la auditoria control a inexactos detectados a partir de indicadores de consistencia del año gravable 2010, tiene como propósito verbal si las cifras registradas en la declaración de renta y complementarios del año gravable 2010, relacionadas con la depuración de la base tributaria por el sistema ordinario, la liquidación del impuesto a cargo, los descuentos tributarios y las retenciones en la fuente, se ajustan a la normatividad vigente, plan que se encuentra firmado por la XXXXX - División de Gestión de Fiscalización-.

Auto de apertura No. 382382012000013 CONCEPTO RENTA AÑO 2010 PERIODO 1 dentro del expediente L1 2010 2012 000013 fecha 2012/03/09 en el que se indica que se inicia investigación a solicitud de la administración, en el cual se encuentra designada la funcionaria XXXXX.

Requerimiento ordinario No. 382382012000011 de fecha 20/03/2012, en el cual se solicita el balance comparativo 2009-2010, el estado de resultados años 2009-2010, los libros auxiliares de cada cuenta por terceros, entre otros documentos.

Documento firmado por el señor Manuel Montañez Herrera de fecha 9 de abril de 2012, en el que solicita a la DIAN, se amplié el plazo para la entrega de la información porque no ha sido posible cumplir con lo solicitado.

Documentado denominado "Control de Llamadas", de fecha 21 de abril de 2012, en el que se indica que el objetivo de la llamada era informar al contribuyente que se le concedía un plazo de quince días más para allegar la información solicitada mediante requerimiento ordinario, el cual es suscrito por XXXXX.

Documentado denominado "Control de Llamadas", de fecha 23 de agosto de 2012, en el que se indicó: "Se marcó el numero 3142198944 no atendió nadie la llamada, se marcó al número 3124434795, la llamada que fue atendida por la señora XXXXX en calidad de esposa del contribuyente se solicita le informe al contribuyente que debe acercarse a la DIAN", el cual es suscrito por XXXXX.

Acta de visita de fecha 19 de octubre de 2012 siendo las 10:20 a.m., en el que se indica que la funcionaria XXXXX atiende al contribuyente Manuel Herrera, "el cual se hace presente en la sede del Dirección Seccional de Leticia con el fin de realizar la siguiente constancia (...) Se presentó en las oficinas de la DIAN el contribuyente con el fin de informar que a la fecha no ha podido recuperar los documentos soportes de la contabilidad relacionada con el año 2010, que fueron entregados al contador de ese entonces y él no se los ha entregado (...). El documento se encuentra firmado por el señor XXXXX y XXXXX.

Documentado denominado "Control de Llamadas", de fecha 7 de marzo de 2013, en el que se indicó: "Atiende la llamada el contribuyente se le recuerda que tiene un compromiso con la DIAN de allegar la información solicitada o de presentar una corrección voluntaria a la declaración inicial, se le informa sobre las sanciones que puede acarrear, responde que lo va hacer su contador que él ya tiene conocimiento al respecto y allegara un proyecto", el cual es suscrito por XXXXX.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

Auto de inspección tributaria de fecha 11 de julio de 2013, en el que se ordena inspeccionar la persona o entidad objeto de investigación, con el objeto de verificar la exactitud de las declaraciones, establecer la existencia de hechos gravados o no.

Auto de inspección contable No. 38238201390002 en el que se ordena realizar inspección contable, de fecha 15 de julio de 2013.

Auto comisorio No. 38-238-2013-0252 de fecha 9 de agosto de 2013, para la práctica probatoria. Acta de visita de fecha 9 de agosto de 2013, realizada por la funcionaria XXXXX, a la empresa del señor XXXXX, en el que se indica que los documentos solicitados se pondrán a disposición de la Dian el día jueves 15 de agosto de 2013.

Auto comisorio No. 38-238-2013-0369 de fecha 15 de octubre de 2013. Inspección de fecha 15 de octubre de 2013 realizada por la funcionaria XXXXX, a la empresa del señor XXXXX.

Acta de terminación de la inspección tributaria, de fecha 1 de noviembre de 2013 con la cual se propone la modificación a la liquidación privada por una diferencia de \$ 130.802.000, firmado por la funcionaria XXXXX y XXXXX.

Requerimiento especial de fecha 5 de noviembre de 2013, junto con el anexo explicativo. Informe acción de fiscalización suscrito por la funcionaria XXXXX, de fecha 16 de diciembre de 2013.

Liquidación oficial de revisión de fecha 8 de Julio de 2014, con un saldo a pagar de \$ 106.322.000, la cual quedó ejecutoriada el 30 de octubre de 2014.

TESTIMONIALES

Diligencia de testimonio del señor XXXXX, recepcionada el 4 de noviembre de 2015, mediante la cual señaló que se le había adelantado un proceso por una declaración de renta, que su contador había dejado mal diligenciada, proceso en el que le impusieron una sanción por \$106.322.000, dinero que a la fecha no ha logrado cancelar.

Indicó que en el trámite de ese proceso la situación que se presentó fue la siguiente:

"me llevo la declaración 2010, la señora XXXXX me citó aquí a la DIAN y me dijo que tenía una irregularidad en la declaración de renta, me solicitó la información de los archivos a lo cual yo le pregunte al contador y no se encontró la información el embolato la información entonces la señora XXXXX me dijo que se podía solucionar el problema pero no se encontraron los archivos y no se pudo hacer nada con esa declaración de renta y como lo he dicho yo no tengo un nivel de estudio uno recurre a los contadores o auxiliar contable que son los que saben los que están haciendo. (...) Pues ella me solicitó que me trajera la contabilidad de ese año al cual yo le comuniqué al auxiliar contable que es XXXXX, no acuerdo que contador firmo esa declaración porque él trabajaba con varios contadores, se consiguió una parte, pero no toda la información se perdió no sé qué haya hecho el señor rivera hablamos, extraoficialmente ella me dijo que me podía ayudar, pero no llegamos a ningún acuerdo porque quedaba mal para ella y para mí."

Respecto a la pregunta de si la señora XXXXX le había solicitado dinero o dádiva por la ayuda que ella le podía hacer, contestó: "(...) Pues si hablamos fuera de la institución por equis cantidad de dinero no me acuerdo el monto, pero en una ocasión se le di dos millones de pesos para evitar la sanción para cuadrar la declaración de renta y evitar la sanción, lo cual no sucedió porque me llevo la sanción y esta es la hora que no he podido pagar. (...) "

Precisó que la primera vez que hablaron, fue con ocasión de una llamada que le realizó la señora XXXXX, para que se presentara en la Dian, lugar en el que le mostró las pruebas de la contabilidad que había solicitado dentro del expediente, y como no contaba con estas, coordinaron encontrarse en el "Brasil" al pie de la iglesia, para que ella le ayudara, señaló que este encuentro se presentó aproximadamente dos años atrás, que lo acompañó su hijo XXXXX, pero que él no alcanzó a escuchar nada porque se había quedado bastante lejos de ellos dos.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

Igualmente, señaló que el día que hizo entrega del dinero, habían coordinado encontrarse a las dos de la tarde en el supermercado "RUKO", lugar al que asistió con su esposa XXXXX, en dicho lugar y por solicitud de la investigada le entregaron el dinero a un "muchacho" que la acompañaba.

Por último, agregó que ese problema acabó con su negocio como comerciante, pues le fueron embargadas sus cuentas, por lo que solicitó que la Dian le quitara esa sanción porque la culpa no había sido de él ni de la señora XXXXX, si no de los contadores.

Testimonio del señor XXXXX recepcionada el 4 de noviembre de mediante la cual afirmo conocer a la investigada porque en el tiempo que trabaja con su hijo XXXXX, ella era la que realizaba las visitas de la DIAN, sin embargo, señaló que nunca le han solicitado dinero o dádiva para favorecer algún proceso adelantado por la DIAN.

Testimonio XXXXX recepcionado el 4 de noviembre de 2015, en su calidad de Directora Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, manifestó al despacho que desde el mes de junio de 2013 la señora XXXXX se ha desempeñado en la División de Gestión de Fiscalización, en la parte de tributario, adelantando entre otras funciones las visitas a los contribuyentes.

Indicó que desde su llegada a la Seccional empezaron a llegar comerciantes a manifestarle que había mucha corrupción y que por los tramites que se realizaban al interior de esa Seccional se solicitaba dinero, puntualmente señaló que el señor de apellido Montañez era el que había denunciado porque estaba perjudicado por un dinero que debía.

Señaló que antes de su llegada la señora XXXXX fue mencionada en unos hechos irregulares relacionados con una solicitud indebida de dinero que esta hizo a una comerciante en desarrollo de una visita tributaria.

Diligencia de inspección administrativa realizada el 12 de febrero del 2016 , en el despacho de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, a través del cual se obtuvo copia del expediente con radicado LI-2010-2012-000013 cuya fecha de apertura es 9 de marzo de 2012, adelantado en contra del contribuyente XXXXX identificado con C.C. XXXXX, el cual consta en un total de 104 folios, el cual fue entregado en CD.

Diligencia de testimonio de la señora XXXXX, (esposa del señor XXXXX) recepcionada el 24 de febrero de 2016, quien afirmó que distinguía a la señora XXXXX porque es funcionaria de la Dian, respecto a los hechos objeto de investigación precisó que ella le había entregado la suma de dos millones de pesos a la "Doctora XXXXX" porque su esposo había llegado a un acuerdo con ella consistente en arreglar una declaración que había quedado mal, precisó que la entrega del dinero se realizó sobre las 9 o 10 de la mañana en el supermercado RUKO, al lado de la caja, advirtiendo que no recordaba la fecha en que ocurrió esto.

Diligencia de testimonio del señor XXXXX recepcionada el 24 de febrero de 2016, (hijo del señor XXXXX), precisó que fue testigo de un encuentro con la señora XXXXX, exactamente señaló lo siguiente: "Si fui testigo, fue en el Brasil aproximadamente cuatro años, la verdad mis papas no me comentaron mucho un día me dijo que lo acompañara que él tenía una cita con una señora en el Brasil y el encuentro fue en la catedral del Brasil en el Parque, ellos se sentaron en una tienda y yo me quede esperar en la moto mientras ellos conversaban".

Indicó que el encuentro fue entre su papá y la investigada, a quien reconoció en desarrollo de la diligencia, tipo cinco o seis de la tarde, sin lograr recordar la fecha exacta en que se desarrolló.

VALORACIÓN EN CONJUNTO DE LAS PRUEBAS

Es necesario resaltar que la finalidad del proceso disciplinario es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que intervienen. Igualmente, que la decisión que toma el operador disciplinario debe estar fundamentada en las pruebas legal y válidamente incorporadas al proceso, las cuales han sido objeto de análisis para el logro de la motivación de la decisión

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

disciplinaria. Por esta razón, se hace necesario valorar en conjunto las pruebas referidas en el caso particular.

En primer lugar, la documentación aportada en el proceso da cuenta que la señora XXXXX, es servidora pública de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, para arribar a esta conclusión tenemos en cuenta el oficio No. 100206214 0002099 de fecha 25 de julio de 2014 y la respuesta remitida por la Subdirectora de Gestión de Personal de la Dian.

Una vez determinada su condición de servidora pública, debemos señalar que se probaron plenamente las funciones de la disciplinada para el momento de la ocurrencia de los hechos investigados. Es así, como del extracto de historia laboral se desprende que la disciplinada se desempeña en la división de gestión de fiscalización en el cargo de Gestor 1 código 301 grado 01, cuyas funciones son apoyar la ejecución de las investigaciones, la práctica de pruebas pertinentes, y conducentes para proyectar la respectiva actuación administrativa en las investigaciones de índole tributario especialmente, partiendo de esta base, se determinó que con ocasión de dichas funciones la señora XXXXX, adelantó la investigación tributaria al señor XXXXX, lo que se puede concluir fácilmente de la inspección administrativa adelantada en la División de Gestión de Fiscalización de la Seccional de Leticia, y del testimonio del señor XXXXX.

Consecuentemente en diligencia de testimonio el señor XXXXX manifestó al Despacho, que, en desarrollo de esa investigación tributaria, la disciplinada le había solicitado indebidamente una suma de dinero para favorecer tal actuación.

En efecto, las manifestaciones realizadas por el señor XXXXX encuentran sustento y se corresponden con la actuación realizada en el expediente tributario, así se tiene probado que esta investigación fue aperturada el 9 de marzo de 2012, asignándole como radicado el L1-2010-2012- que tenía como objeto realizar control a inexactos detectados a partir de indicadores de consistencia del año gravable 2010, que el 20 de marzo de 2012 se profirió requerimiento ordinario en el que se solicitaban los balances comparativos, libros auxiliares y otros documentos.

Ahora bien, según relató, fue citado por la investigada a las instalaciones de la Dian, para que allegara cierta documentación contable, prueba de esta afirmación lo constituye el documento obrante en el expediente tributario firmado por la señora XXXXX denominado "Control de Llamadas", de fecha 23 de agosto de 2012 en el que se consignó: <<Se marcó el numero XXXXX no atendió nadie la llamada, se marcó al número XXXXX, la llamada que fue atendida por la señora XXXXX en calidad de esposa del contribuyente se solicita le informe al contribuyente que debe acercarse a la DIAN>>.

Igualmente, manifestó que ante la citación se presentó en la Dian, oportunidad en la que le informó a la investigada que no había logrado conseguir los documentos, prueba de ello lo constituye el "Acta de Visita" de fecha 19 octubre de 2012, en la que consignó lo siguiente: <<(…) Se presentó en las oficinas de la DIAN el contribuyente con el fin de informar que a la fecha no ha podido recuperar los documentos soportes de la contabilidad relacionada con el año 2010, que fueron entregados al contador de ese entonces y él no se los ha entregado (...)>>.

De conformidad con lo anterior, para el Despacho no hay duda alguna, respecto a los anteriores hechos narrados por el testigo, pues ciertamente, su versión esta soportada en la prueba documental recopilada, que permite concluir que la Seccional de Leticia le adelantó una investigación tributaria al señor XXXXX, la cual estuvo a cargo de la disciplinada quien, en desarrollo de la misma, lo requirió para que allegara la documentación contable y que efectivamente el señor XXXXX, no logró encontrar los documentos requeridos.

Ahora bien, manifestó el señor XXXXX que ante la imposibilidad que tuvo de conseguir estos documentos, la señora XXXXX le manifestó que: "se podía solucionar el problema", y la manera de remediarlo según afirmó el señor XXXXX fue entregarle dos millones de pesos "para cuadrar la declaración de renta y evitar la sanción", lo cual se concretó en días posteriores.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

Respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron estos hechos, refirió que fueron dos momentos, el primero fue un encuentro en el parque que queda en el "Brasil", del cual fue testigo su hijo XXXXX, quien ciertamente en declaración juramentada corroboró las circunstancias descritas por el señor Manuel, pues afirmó, que presencié el encuentro entre su papa y la investigada, el cual se desarrolló en el parque el "Brasil", observó que ellos se sentaron en una tienda, y mientras conversaban él se quedó esperando en la moto.

En relación con el segundo encuentro en el que se le entregaron los dos millones de pesos a la investigada, manifestó que coordinaron encontrarse antes de las dos de la tarde en el supermercado "RUKO" y en la parte de al fondo se le hizo entrega del dinero a un "muchacho" que la acompañaba, después de eso refirió que la investigada se dirigió a su trabajo y él a su casa junto con su esposa, estos hechos fueron a su vez ratificados por la señora XXXXX (esposa del señor XXXXX), pues afirmó categóricamente que le había entregado el dinero a la señora XXXXX porque su esposo había llegado a un acuerdo con ella para que les colaborara con una declaración que les había quedado mal, que la entrega del dinero se había realizado en el supermercado Ruko y que en ese momento la investigada estaba acompañada por un "muchacho".

De acuerdo a lo expuesto, la conclusión es que está demostrado con la certeza exigida en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, que el día 19 de octubre de 2012 la disciplinada se reunió en las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Leticia con el contribuyente Manuel Montañez Herrera, a quien ofreció su ayuda y solicitó "hablar afuera sobre esa situación" (afirmado por el quejoso), para lo cual se citaron en días posteriores en el Parque conocido como "El Brasil", el cual queda ubicado al pie de la iglesia. Durante la misma, la señora XXXXX, le solicitó la suma de dos millones de pesos, para favorecer la investigación tributaria, solicitud que se concretó posteriormente con la entrega del dinero en las instalaciones del supermercado "RUKO".

DE LA TIPICIDAD DISCIPLINARIA

El Artículo 48 de la Ley 734 de 2002 establece un catálogo taxativo de conductas gravísimas, dentro de las cuales en el numeral primero encontramos que: "Son faltas gravísimas las siguientes: 1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la Ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo".

La norma trascrita es un tipo en blanco que nos remite a la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano). De este modo, es preciso realizar un ejercicio de adecuación típica penal, con el objeto de que, por remisión, dicha infracción a la luz de lo dispuesto por el artículo 48 numeral primero del Código Disciplinario Único, corresponda a un tipo disciplinario.

Por su parte, la conducta endilgada a la disciplinada XXXXX corresponde, desde la perspectiva objetiva, a la descripción típica consagrada en el artículo 404 de la norma penal adjetiva, la cual establece:

"Concusión. El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años".

Ahora bien, se hace necesario efectuar un estudio del tipo penal referido concusión, con el fin de determinar si la funcionaria XXXXX incurrió en el mismo.

En primer lugar, este tipo penal protege el bien jurídico de la administración pública, esto es, la probidad y rectitud en la función pública. A su turno, nos encontramos frente a un delito especial, es decir, dentro de los elementos del tipo objetivo encontramos un sujeto activo cualificado jurídicamente y singular, implicando que la conducta debe ser cometida por un servidor público que abusa de su cargo o función.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

Sobre la calidad del sujeto activo, existen diferentes pruebas que logran concluir que la señora XXXXX es servidora pública adscrita a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, a saber: el oficio No. 100206214 0002099 de fecha 25 de julio de 2014 y la respuesta remitida por la Subdirectora de Gestion de Personal de la Dian.

Determinado que se trata de una servidora pública, este despacho debe determinar si la funcionaria actuó abusando de su cargo o de sus funciones. Es importante aclarar que dentro de las funciones que desempeñaba la señora XXXXX dentro de la División de Gestión de Fiscalización de la Seccional de Leticia, estaba adelantar las investigaciones tributarias a los contribuyentes, así una vez revisada su carga laboral, se estableció que ciertamente tuvo a cargo el expediente L1-2010-2012-000013 aperturado el 9 de marzo de 2012 contra el contribuyente XXXXX, cuyo objeto era verificar las cifras registradas en la declaración de renta y complementarios del año gravable 2010.

Establecido que el sujeto activo cumple con las condiciones de su calificación, así como que actuó abusando de su cargo y función, debe realizarse la adecuación al verbo rector, esto es, saber si la disciplinada conjugó el mismo. Para ese fin, tenemos que el tipo objetivo de concusión cuenta con un verbo rector compuesto alternativo -constreñir, inducir o solicitar-.

Para arribar a esta conclusión, se partió de las manifestaciones dadas por el señor XXXXX, confrontadas con la prueba documental -expediente tributario-, a partir de las cuales se concluyó que el día 23 de agosto de 2012, la disciplinada lo contactó vía telefónicamente y lo citó a las instalaciones de la Dian, citación que se concretó el 19 de octubre de 2012, oportunidad en la que el señor Montañez Herrera le hizo saber a la señora XXXXX que no había logrado ubicar la documentación contable, situación de la cual se aprovechó la disciplinada, y "extraoficialmente" le ofreció su "ayuda", la cual consistió en solicitarle la suma de dos millones de pesos para cuadrar la declaración de renta y así evitar la sanción, es así que por tener a su cargo esa investigación tributaria, hizo pensar al señor XXXXX que podía influir a su favor en la decisión final que se tomara en el expediente.

Precisó que la primera vez que habló con ella fue al lado del Parque que queda en el Brasil al pie de la iglesia en donde hablaron para que le colaborara con ese problema y para la entrega del dinero se citaron antes de las dos de la tarde en el supermercado Ruko, en el cual se hizo la entrega de los dos millones de pesos a un muchacho que la acompañaba, indicó que su hijo XXXXX fue testigo de la reunión en el Brasil y que su esposa XXXXX lo había acompañado a la entrega del dinero.

Respecto al primer encuentro, este Despacho recaudó el testimonio del señor XXXXX (hijo del señor XXXXX), quien manifestó que fue testigo del encuentro entre su padre y la investigada, a quien reconoció sin dubitación alguna en desarrollo de la diligencia testimonial, particularmente manifestó: "Si fui testigo, fue en el Brasil aproximadamente cuatro años, la verdad mis papas no me comentaron mucho un día me dijo que lo acompañara que él tenía una cita con una señora en el Brasil y el encuentro fue en la catedral del Brasil en el Parque, ellos se sentaron en una tienda y yo me quede esperar en la moto mientras ellos conversaban."

En lo relacionado con el segundo encuentro, se contó con el testimonio de la señora XXXXX (esposa del señor XXXXX) quien manifestó que ella le había entregado la suma de dos millones de pesos a la "Doctora XXXXX" porque su esposo había llegado a un acuerdo con ella consistente en arreglar una declaración que había quedado mal, que la entrega del dinero se realizó sobre las 9 o 10 de la mañana en el supermercado RUKO, al lado de la caja, sin lograr precisar la fecha de estos hechos.

En cuanto a las versiones rendidas por el señor XXXXX y la señora XXXXX, el Despacho encuentra que incurren en dos contradicciones, pues por un lado el señor XXXXX indicó que para el segundo encuentro se citaron antes de las dos de la tarde en el supermercado el Ruko, y que al interior de este le entregó el dinero, y por su parte la señora XXXXX precisó que la entrega del dinero se realizó sobre las 9 o 10 de la mañana en el supermercado el Ruko al lado de la caja.

Sobre este aspecto, resulta oportuno resaltar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de manera constante ha señalado que las contradicciones en que incurre un mismo testigo, o unos con otros, en modo alguno pueden constituir razón suficiente para desechar su credibilidad, casos en los cuales es labor del funcionario judicial entrar a establecer, visto el contenido de las distintas

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

declaraciones, con apoyo en las reglas de la sana crítica, a que sectores de una determinada versión o versiones les concede mérito y a cuál o cuáles no.

Basta traer a colación el pronunciamiento realizado dentro de la providencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, radicado No. 23154 del 6 de abril de 2005, en el que sobre el particular expresó:

"Pero al margen de lo anterior, no sobra recordar al censor que la doctrina de la Corte ha insistido en afirmar que las simples contradicciones en las versiones vertidas por determinado testigo no son suficientes para restarle todo mérito, gozando el sentenciador de la facultad de determinar, siguiendo las reglas de la sana crítica, que son verosímiles en parte, o que todas son increíbles o que alguna o algunas de ellas tienen aptitud para mostrar la verdad".

En consonancia con lo anterior, se tiene que, en pronunciamiento de esa misma corporación, dentro del radicado No. 13838 del 31 de mayo de 2001, se indicó que:

<< (...) resulta habitual el que cada uno de los testigos narre los hechos de acuerdo con la particular perspectiva o visión que de ellos tuvieron, en que tal eventualidad implique restar credibilidad a sus afirmaciones, apreciación que se aviene al criterio depurado por la jurisprudencia, de acuerdo con el cual puede ocurrir que varios relatos acerca de un mismo evento no sean totalmente coincidentes, mas no por ello debe restárseles credibilidad y desestimárseles, ya que esa es una situación que resulta normal si es tomado en cuenta que no todas las personas que presencian un hecho tiene la misma capacidad de apreciación, ni se encuentran dentro del mismo plano de percepción visual o auditiva, y que además de ello, las discrepancias que se presentan en el caso sub judice no son de contenido sustancial, como para llegar a pensar, razonablemente, que los testigos no estuvieron presentes en la escena del crimen, o que sus afirmaciones sobre lo que sucedió no son verdaderas (...)>>

Dentro del radicado No. 23283 del 18 de junio de 2008, se dijo que: << (...) por aspectos esenciales debe entenderse, en estos casos, aquellos que son sustanciales, principales o notables a lo que constituye el objeto de la declaración y que en términos jurídico penales, se traducen en todos los supuestos de hecho que conforman el núcleo de la imputación formulada en contra del procesado e, igualmente todas las circunstancias fácticas de las que pueda derivarse algún argumento trascendente acerca de la verdad o falsedad de dichos enunciados (...) >>

Aunado a lo anterior, debe decirse que en materia de valoración de testimonios es perfectamente factible y viable, que los testigos que narran los hechos investigados después transcurrido bastante tiempo de su ocurrencia, no hagan una reproducción exacta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo acontecido, pues los órganos de la percepción, la atención visual y auditiva, las condiciones y apreciación del tiempo, la emotividad, la evocación y la conservación del recuerdo se va deteriorando con el paso de los años.

Por ende, y atendiendo los pronunciamientos expuestos, para el caso en concreto, debe indicarse en primer lugar que desde la fecha de recepción de los testimonios (noviembre de 2015) a la fecha de ocurrencia de los hechos cuestionados (octubre de 2012) han transcurrido más de tres años, por lo que es perfectamente válido que no hagan un recuento exacto de las circunstancias temporo - espaciales en que la disciplinada realizó la solicitud indebida de dinero al señor XXXXX, por lo que al momento de realizar la valoración de estas versiones, este operador debe analizar de manera más cuidadosa que los hechos descritos por estos testigos no incurran en contradicciones graves sobre las circunstancias principales en que se cometió la conducta reprochada.

Así para el caso en concreto, resulta acertado otorgarle total credibilidad a las declaraciones rendidas por los testigos aludidos, porque si bien incurrieron en las imprecisiones anotadas, cierto es que las mismas no son indicativas de que sus afirmaciones sobre lo que sucedió no son verdaderas, ni desvirtúan el núcleo principal de la imputación formulada a la disciplinada, pues el señor XXXXX y la señora XXXXX, fueron precisos y coincidentes en señalar que:

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

^ i) sostuvieron un encuentro con la disciplinada XXXXX, ii) al interior del supermercado el "Ruko", iii) encuentro que se desarrolló en horas previas a las dos de la tarde, iv) lugar en el que por solicitud de la disciplinada le entregaron la suma de dos millones de pesos, vi) con el fin de arreglar la declaración de renta y de esta manera evitar la sanción tributaria vii) y que en dicho momento la señora XXXXX estaba en compañía de un "muchacho", lo anterior evidencia, que no existen contradicciones sobre las circunstancias principales de los hechos cuestionados.

Precisada esta situación, tenemos como ingrediente normativo del tipo objetivo del punible de concusión que la solicitud debe ser dinero o cualquier otra utilidad indebida. Sobre este punto, con el testimonio del señor XXXXX y XXXXX, podemos concluir que la funcionaria buscaba beneficiarse del inconveniente que tenía el señor XXXXX con la documentación contable, para lo cual lo contactó, le ofreció su ayuda y concretamente le solicitó la suma de dos millones de pesos, haciéndole creer que por ser funcionaria de la DIAN y estar a cargo de la investigación tributaria, podía evitar que se le impusiera la sanción.

Por las razones aducidas y estudiados uno a uno los elementos del tipo objetivo, no cabe duda que la disciplinada realizó la conducta típica descrita en la ley como delito. Consecuentemente, la conducta reprochada a la señora XXXXX y que se refiere a la vulneración del artículo 48 numeral 1° de la Ley 734 de 2002, y por remisión al artículo 404 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano), se encuentra acreditada en lo atinente a la tipicidad.

DE LA ILICITUD SUSTANCIAL

Es claro que los servidores públicos deben tener siempre presente el deber de sujetar su función a asegurar la prevalencia del interés general, de donde surge su responsabilidad con ocasión de la vulneración de los principios de legalidad, transparencia, honradez y lealtad.

De esa forma, la conducta típica enunciada de manera previa, resulta, hasta el momento, sustancialmente contraria al ordenamiento jurídico vigente, puesto que la servidora implicada debió actuar como lo demandan las normas de carácter legal y reglamentario, pese a lo cual dejó de hacerlo, circunstancia ésta que estructura la ilicitud sustancial del comportamiento que surge de la contrariedad entre el actuar oficial y la preceptiva que impone actuar de determinada manera, sin abusar de su cargo, la que califica su comportamiento como trasgresor de la normatividad que rige su actuar y en consecuencia de la disposición disciplinaria.

Aunado a lo anterior, resulta importante resaltar que abusar de su cargo para solicitar indebidamente dinero con el fin de obtener un beneficio económico particular, afectó la transparencia, lealtad y pulcritud exigible de su condición de servidora pública, comportamientos que hasta la fecha no encuentran justificación, configurándose de ese modo el elemento de ilicitud sustancial o antijuridicidad que demanda la estructuración de la falta disciplinaria. Esto, en tanto, al asumir sus cargos, los servidores públicos se comprometen a cumplir con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias (Arts. 6 y 122 Constitución Política y 27 Código Disciplinario Único), lo que significa que la realización de comportamientos expresamente prohibidos o calificados como atentatorios del ordenamiento, sin ninguna justificación, pueden resultar violatorios de sus deberes funcionales expresamente definidos.

Al respecto, debe señalarse que la conducta resulta antijurídica desde todo punto de vista, porque con ella la disciplinada atentó contra los principios de la administración tales como la legalidad, la buena fe y la transparencia, al actuar contrariamente al deber de fidelidad, lealtad y diligencia esperado para con la administración pública.

Conforme a lo anterior, es válido declarar abastecido el presupuesto de antijuridicidad de la conducta al tenor de lo señalado en el artículo 5° de la Ley 734 de 2002, ya que hubo falta al deber funcional sin justificación alguna conocida.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

6.5 CULPABILIDAD

Superado y verificado el análisis de tipicidad e ilicitud sustancial de la conducta que le fue imputada a la funcionaria XXXXX, debe este despacho pronunciarse sobre la culpabilidad como elemento del tipo disciplinario.

En orden de lo expuesto, el Artículo 13 del Código Disciplinario Único establece que las faltas son sancionables a título de dolo o culpa, por lo tanto, se procede a realizar un análisis de culpabilidad en el presente caso.

En tal sentido, el pliego de cargos fijó el grado de culpabilidad en dolo, situación que se mantiene en el mismo sentido en este fallo de primera instancia, atendiendo la forma en la cual se exteriorizó el comportamiento.

Para arribar a esta conclusión, tenemos que la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Consecuentemente, los elementos estructurales del dolo son el momento intelectual o cognoscitivo y el momento volitivo, los cuales deben estar presentes para que se actúe bajo una modalidad dolosa y no nos encontremos frente a un supuesto de responsabilidad objetiva, proscrito constitucionalmente.

En el caso particular y en lo atinente al elemento cognitivo del dolo, en el proceso hay distintas pruebas que confirman su existencia, a saber: En primer lugar, la funcionaria XXXXX, para la época de la conducta, laboraba en la División de Gestión de Fiscalización de la Seccional de Leticia. En este contexto, es dable afirmar sabía que exigir dinero para realizar un trámite propio de sus funciones era prohibido y por otro, sabía que abusaba de su cargo y de su posición como servidor público para efectuar la solicitud. No obstante, a sabiendas, actuó de manera equivocada, lo cual permite a este Despacho mantener la calificación dolosa en el proceder del funcionario disciplinado, quien decidió voluntaria y libremente actuar de forma contraria a derecho, sin que medie prueba que demuestre algún vicio en su conocimiento, juicio, o determinación para proceder.

Sobre el aspecto volitivo, este despacho señala que a pesar de que el disciplinado conocía la ilicitud de su comportamiento, dirigió libremente su actuación para alcanzar un propósito sin que su voluntad se haya visto afectada, pues al momento de analizar la culpabilidad se verifica que conocía los elementos del tipo objetivo y no se evidencia en la actuación ningún tipo de error de prohibición por parte del agente de la conducta disciplinable y tampoco recae sobre él alguna causal de inimputabilidad.

Por estas razones, estima el despacho que está plenamente demostrado que la conducta reprochada a la señora XXXXX fue cometida a título de DOLO, pues conocía los hechos de la infracción y quiso su realización.

DE LA CONTESTACIÓN A LOS ARGUMENTOS DE LA INVESTIGADA

Por metodología y para un mayor entendimiento de la presente decisión, se dará respuesta por separado a cada uno de los argumentos brindados en ejercicio de la defensa tanto material como técnica, así:

Ha de indicarse que la disciplinada en su versión libre, descargos y alegatos de conclusión, elevó cuatro argumentos principales, los cuales serán contestados en el siguiente orden:

Consideró que el haberse adelantado la actuación disciplinaria por una queja formulada por una "persona inexistente", era indicativo que lo único que se pretendía era perjudicarla con la imputación de conductas ilegales que nunca cometió, al respecto el Despacho debe indicar que si bien las verificaciones realizadas arrojaron como resultado que la dirección aportada por el señor XXXXX (quejoso) no existe, que no reside en la zona y que no lo conocen, no lo es menos que por solo este hecho se puede aseverar que la conducta no fue cometida por la disciplinada, por el contrario siendo el Estado titular de la acción disciplinaria, debe atender a las señales que lo puedan alertar y conducir hacia el conocimiento de conductas tipificables en el espectro de faltas disciplinarias.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

Por ello mismo, cuando quiera que se presente una queja la respectiva autoridad disciplinaria deberá ordenar el adelantamiento de la correspondiente indagación preliminar en orden a establecer la veracidad de los hechos, sus autores y circunstancias que permitan establecer si se dan o no los presupuestos básicos para abrir formal averiguación disciplinaria en contra del autor o autores. Tan es así la facultad que otorga la constitución y la ley a las autoridades disciplinarias, que excepcionalmente la investigación disciplinaria puede adelantarse por "anónimos" que aporten información verificable y que permita orientar en debida forma la investigación.

Por lo anterior, el Despacho considera que el argumento elevado por la disciplinada carece de fundamento, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 69 de la ley 734 de 2002, establece que la acción disciplinaria se iniciará y adelantará i) de oficio, ii) por información proveniente de servidor público iii) o de otro medio que amerite credibilidad iv) o por queja formulada por cualquier persona, así, las cosas y en cumplimiento de los deberes impuestos como autoridad disciplinaria y ante la denuncia de hechos que podían constituir la comisión de una falta disciplinaria, este operador adelantó la presente actuación, decretó, practicó y recolectó las pruebas que se estimaron conducentes, pertinentes y útiles, las cuales después de un análisis crítico permitió determinar la responsabilidad disciplinaria de la servidora pública XXXXX.

Adujo que este Despacho valoró en su contra las correctas actuaciones que adelantó dentro de la investigación tributaria, las cuales en su consideración demostraron que actuó conforme a la normatividad tributaria vigente y que no tuvo interés diferente a establecer la realidad contable y fiscal del contribuyente XXXXX, afirmando categóricamente que, de aceptarse esa teoría, el resultado no hubiera sido la imposición de una sanción.

Sobre este punto, este operador disciplinario debe indicar en primer lugar que a lo largo de esta actuación no se cuestionó que la investigación tributaria a cargo de la disciplinada dentro del expediente tributario del señor XXXXX, se hubiere adelantado en contravía de la normatividad tributaria vigente, por el contrario, lo que se reprochó es que la señora XXXXX, abusando de su cargo y función, y aprovechando su investidura de funcionaria pública a cargo de la investigación tributaria del contribuyente mencionado, solicitó indebidamente una suma de dinero.

Adicional a lo anterior, debe indicarse que la sola afirmación de que la imposición de la sanción tributaria desvirtúa la solicitud indebida de dinero realizada al señor XXXXX, no es suficiente para restarle credibilidad a los testimonios de los señores XXXXX, XXXXX y XXXXX, porque estos fueron claros y precisos al relatar las circunstancias principales en que se cometió la solicitud indebida de dinero, como bien se dilucido en los acápites de valoración probatoria y tipicidad.

En segundo lugar, porque para la configuración del tipo penal endilgado basta la sola solicitud de dinero u otra utilidad indebida, independientemente de que el servidor público cumpla lo prometido en virtud de la solicitud indebida, máxime cuando se tiene que la disciplinada en ejercicio de sus funciones le correspondía adelantar la investigación tributaria y presentar un informe final a partir del cual se tomaría la decisión de fondo, bajo ese contexto se tiene que la jurisprudencia de la Corte ha considerado que el servidor público puede cometer la conducta punible aun cuando no tenga la competencia para decidir el asunto que le sirve de pretexto para hacer la exigencia indebida.

En el caso sub examine, es claro que la disciplinada utilizó indebidamente la preeminencia de su cargo e hizo pensar al señor XXXXX que por el hecho de estar a su cargo la investigación tributaria, podía evitar que se le impusiera la sanción, para lo cual aprovechó la preocupación que tenía el contribuyente por no encontrar los documentos contables requeridos, y le ofreció su "ayuda" para supuestamente evitar que le impusiera la sanción, todo a cambio de que obtener un beneficio económico propio, por el desarrollo de su función.

Por último, consideró que la única prueba que se arrimó a la actuación fue el testimonio amañado del señor XXXXX y su familia, los cuales tacha de falsos, porque incurrieron en contradicciones en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, precisando que las inconsistencias se presentaron en la hora de los hechos, en el lugar específico de la entrega del dinero y de la persona a quien se le entregó el mismo.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

Respecto a tal afirmación, se precisa que este análisis se realizó en el acápite denominado "DE LA TIPICIDAD DISCIPLINARIA", en el que se concluyó que era perfectamente factible y viable, que los testigos que narran los hechos investigados después de más de tres años de su ocurrencia, no hagan una reproducción exacta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo acontecido, pues los órganos de la percepción, la atención visual y auditiva, las condiciones y apreciación del tiempo, la emotividad, la evocación y la conservación del recuerdo se va deteriorando con el paso de los años.

Por lo que fundamentado en los pronunciamientos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se concluyó que en los testimonios de los señores XXXXX y XXXXX, merecían total credibilidad, pues si bien se incurrieron en inconsistencias, cierto es que no se variaron o contradijeron las circunstancias principales en que se cometió la conducta reprochada, estimándose que fueron claros, coincidentes y precisos, en señalar que: i) sostuvieron un encuentro con la disciplinada XXXXX, ii) al interior del supermercado el "Ruko", iii) encuentro que se desarrolló en horas previas a las dos de la tarde, iv) lugar en el que por solicitud de la disciplinada le entregaron la suma de dos millones de pesos, recordando adicionalmente la presencia de "un muchacho" que la acompañaba, vi) y que la entrega de ese dinero tenía un fin específico, arreglar la declaración de renta y de esta manera evitar la sanción tributaria.

DE LA CONTESTACION DE LOS ARGUMENTOS ELEVADOS POR LA DEFENSORA DE OFICIO XXXXX

1. Los argumentos elevados por la defensora de oficio guardan estrecha relación con las consideraciones finales presentadas por la disciplinada, por ende, en lo relacionado con las contradicciones presentadas en cuanto a las circunstancias de tiempo modo y lugar de los hechos imputados, este Despacho indica que abran de tenerse las consideraciones realizadas los acápites "DE LA TIPICIDAD DISCIPLINARIA" y "DE LA CONTESTACIÓN A LOS ARGUMENTOS DE LA INVESTIGADA" numeral 3, como como respuesta a este argumento.

En este mismo punto, debe indicarse que carece de fundamento alguno, la afirmación elevada por la apoderada del disciplinado, a través de la cual pretende sostener que al no recordarse exactamente la fecha de los hechos, no hay certeza de lo sucedido, pues si bien, los testigos en sus diligencias manifestaron que no lograban precisar la fecha exacta de los hechos reprochados, cierto es que las circunstancias de tiempo, modo y lugar por ellos descritas fueron confrontadas y corroboradas con las actuaciones adelantadas en el expediente tributario, y en ese contexto, se logró probar que:

Ciertamente el 23 de agosto de 2012, la disciplinada se comunicó vía telefónicamente con la señora XXXXX, a quien le dejó el mensaje que el señor XXXXX debía presentarse en las instalaciones de la Dian.

Que dando cumplimiento a la citación elevada por la señora XXXXX, el día 19 de octubre de 2012 el señor XXXXX se presentó en la Dian y le manifestó a la investigada que no había logrado recaudar los documentos contables que requería, y que fue en ese momento, en que la funcionaria aprovechando su investidura le ofreció su "ayuda" para cuadrar la declaración de renta y evitar la sanción.

Y que en días posteriores a esta fecha se realizaron los dos encuentros, el primero de ellos, en el que se concretó la solicitud de dinero, y que se realizó en el parque el Brasil, encuentro que fue corroborado por el hijo del señor XXXXX, quien reconoció a la funcionaria investigada como la persona con quien se encontró su padre en esa oportunidad en el parque el "Brasil" y el segundo encuentro en el que se realizó la entrega del dinero, del cual fue testigo también la esposa del señor XXXXX, persona que sin dubitación alguna, indicó que se encontraron en el interior del supermercado el Ruko, que la funcionaria investigada se encontraba en compañía de un muchacho, y que le entregaron la suma de dos millones de pesos para evitar la sanción.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

Así las cosas, y retomando los argumentos ampliamente expuestos a lo largo de este proveído, para este Despacho es claro que los testimonios recaudados merecen total credibilidad y por el solo hecho de incurrir en algunas imprecisiones no pueden ser simplemente desechados o desestimados, pues sus versiones fueron coincidentes en las circunstancias principales y bases de la imputación realizada a la señora XXXXX.

En segundo lugar, adujo que la señora XXXXX y el señor XXXXX, al tener un vínculo familiar con el señor XXXXX, tenían un interés evidente en favorecer su versión, por lo que debe restársele total credibilidad a sus manifestaciones, dado que se estaría afectando la imparcialidad de los testigos.

En relación con este punto, el Despacho debe señalar que se aparta totalmente de esta afirmación, la cual además carece de fundamentación alguna, pues no basta simplemente alegar que por la existencia de un vínculo familiar entre los testigos sus versiones carecen de credibilidad y desvirtúan los hechos endilgados, por el contrario, cuando se presenta este tipo de conexiones entre los testigos, es preciso valorar con mayor exigencia y profundidad sus dichos, pues así lo ha determinado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto de asuntos similares:

"Es claro que en ocasiones el testimonio de familiares o amigos puede afectar la objetividad, especialmente cuando se orienta a favorecer al allegado, caso en el cual, lo aconsejable conforme a las reglas de la sana crítica no es, sin más, desestimarlo y marginarlo por provenir de tales personas, sino, de una parte, someterlo a un examen intrínseco más detallado y profundo en 'lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la personalidad del declarante, a la forma como hubiere declarado y las singularidades que puedan observarse en el testimonio' (artículo 277 de la Ley 600 de 2000).

de otra, emprender un cuidadoso análisis extrínseco, en cuanto se refiere a verificar su concatenación con el resto de medios de convicción que integran el recaudo probatorio, de manera que sólo si de manera insular denota total ausencia de coherencia con las demás pruebas que se ofrecen confiables, podrá por regla general en tal caso, como en todos los demás, restárseles valor acreditativo, desde luego, exponiendo razonadamente los motivos para arribar a tal conclusión a fin de preservar la exigencia de debida motivación de las providencias judiciales, que se corresponde con la más amplia noción del derecho fundamental al debido proceso. (...)"

A partir de lo anterior, debe indicarse en primer lugar que la defensa se limitó a indicar que el vínculo familiar denotaba un "evidente interés", sin embargo no se argumentó ni explicó cuál era ese evidente interés, ahora bien si este Despacho entrara a considerar tal afirmación, no encuentra de qué manera las declaraciones vertidas por estos en diligencias puedan favorecer en alguna forma al señor XXXXX, en tanto a la fecha la decisión que impuso la sanción se encuentra en firme y no se puede retrotraer o re abrir la investigación tributaria, para que de alguna manera con las manifestaciones rendidas en este plenario se deje sin efecto la sanción.

Adicionalmente, y como bien se ha indicado el examen del testigo en estos casos debe realizarse de manera más cuidadosa y detallada, exponiéndose razonadamente los motivos para arribar a tal conclusión, que para el caso en concreto no es otra, que otorgarles total credibilidad a las declaraciones rendidas por XXXXX, XXXXX y XXXXX, reiterándose las consideraciones expuestas en los acápites "DE LA TIPICIDAD DISCIPLINARIA" y "DE LA CONTESTACIÓN A LOS ARGUMENTOS DE LA INVESTIGADA" numeral 3, en los cuales se dejó claro^ que sus versiones fueron coincidentes en las circunstancias principales y bases de la imputación realizada a la señora XXXXX.

Afirmó que al no recolectarse las videograbaciones del supermercado el Ruko, no se había probado efectivamente la ocurrencia de los hechos, sobre este punto el Despacho debe indicar que se ha realizado un incorrecto análisis de la inspección realizada en las instalaciones del supermercado el Ruko, pues los resultados de la misma fueron que los el disco duro de almacenamiento guarda las imágenes, aproximadamente por tres meses, y que al no ser reemplazado los archivos eran regrabados con nuevas imágenes, lo que imposibilitaba la extracción y obtención de imágenes de hace seis meses.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

Si se realiza un análisis adecuado de dicha prueba, es claro que no fue posible obtener las videgrabaciones porque el sistema de almacenaje utilizado en dicho Establecimiento no permite recopilar videgrabaciones de más de seis meses, y como quiera que los hechos investigados datan del año 2012, es evidente que no se pueden recaudar, sin embargo la imposibilidad de su recolección no es prueba de que los hechos no se hayan probado, máxime si se tiene en cuenta que esta no fue la única prueba recaudada por el Despacho, pues dentro del plenario, obran testimonios y documentos que permitieron realizar la reconstrucción de los hechos imputados y determinar la responsabilidad disciplinaria de la señora XXXXX.

CALIFICACIÓN DE LA FALTA

En el Auto de No. 17406-00027 del 10 de noviembre de 2016, dentro del cual se profirió el cargo a la disciplinada, se imputó provisionalmente la comisión de la falta como GRAVÍSIMA, en cuanto constituye la realización de una conducta contemplada en el Numeral 1 del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Luego de agotadas las etapas del proceso disciplinario adelantado y del recaudo probatorio, concluye este despacho que la conducta reprochada a la inculpada, realmente fue cometida por ella y, en efecto, como se calificó en la precitada providencia, corresponde a la tipología de las faltas que por expresa disposición legal fueron consagradas como GRAVÍSIMAS.

Sobre este punto, conforme a los lineamientos expuestos al respecto por la Corte Constitucional en la sentencia C-181 de 2002, este tipo de faltas no requieren estudio o análisis de graduación y, por ende, para los fines propios de esta providencia atendiendo al expreso y taxativo mandato legal será tenida en cuenta como GRAVISIMA:

"FALTA DISCIPLINARIA - Sistema de graduación no opera en la de carácter gravísimo. (...) en tratándose de las faltas que han sido catalogadas como gravísimas por expresa denominación legal, el sistema de graduación del artículo 27 no opera. En otras palabras, y de acuerdo con la providencia en cita, el hecho de que los criterios para determinar la gravedad de las faltas disciplinarias sólo se apliquen a las faltas graves o leves, mas no a las gravísimas, se encuentra ajustado a las prescripciones de la Carta Fundamental. (...) Como ya se dijo, son precisas las conductas que se encuentran estatuidas como faltas gravísimas, respecto de las cuales no cabe ningún tipo de gradación (arts. 25 y 26)."

La consideración anterior se justifica, dice la Corporación, ya que el legislador es autónomo para definir, dentro de los márgenes de lo razonable, los criterios aplicables al ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado (...)

Sin que sea necesario hacer comentario adicional a la enfática consideración de la Corte, esta Corporación se estará a lo resuelto en la Sentencia C-708 de 199967[13] (confirmada en la Sentencia C- 292 de 2000) respecto de la constitucionalidad de los apartes subrayados de los artículos 27 de la Ley 200 de 1995 pues, contrario a lo sostenido por el actor, las faltas gravísimas, cuando su comisión ha sido comprobada y adjudicada a título de dolo o culpa, no son susceptibles de graduación para efectos de determinación de la sanción."

Así las cosas, en el presente caso, siendo la conducta reprochada a la disciplinada, la cual se encuentra probada, de aquellas que el propio legislador instituyó como GRAVISIMA, ninguna determinación diferente en cuanto a la gravedad de la falta puede hacer este censor.

DE LA SANCION POR IMPONER

Demostrado quedó en el presente proceso que la funcionaria XXXXX, quien para la época de los hechos que se investigan prestaba sus servicios como Gestor Código 301 grado 01 en la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, es responsable de cometer la falta disciplinaria GRAVÍSIMA contenida en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

Consecuentemente, configurados los presupuestos legales exigidos por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, al obrar en el proceso prueba acerca de la certeza de la existencia de la falta y de la responsabilidad de la involucrada, es menester proceder a determinar la sanción a imponer, para lo cual se partirá de los siguientes presupuestos: La conducta cometida por el disciplinado fue determinada como FALTA GRAVISIMA DOLOSA, cuya sanción está establecida en el artículo 44 del Código Disciplinario Único, así:

"Artículo 44. Clases de sanciones. El servidor público está sometido a las siguientes sanciones:

1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima. (...)"

Respecto al término de inhabilidad general, el artículo 46 de la Ley 734 de 2002 establece que debe graduarse dentro de unos rangos preestablecidos de la siguiente manera:

"Artículo 46. Límite de las sanciones. La inhabilidad general será de diez a veinte años, pero cuando afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente (...)".

Aclarado lo anterior, al tenor del artículo 47 de la ley disciplinaria que fija los criterios a tener en cuenta para determinar el término de duración de la inhabilidad, este despacho encuentra necesario tener en cuenta que la procesada no ha sido sancionada fiscal o disciplinariamente y que, al momento de la comisión de la falta, no pertenecía al nivel directivo o ejecutivo de la entidad, así que, a pesar de lo reprochable de su conducta, no se afectaron derechos fundamentales; circunstancias que serán evaluadas en su favor.

Teniendo en cuenta lo anterior y sumado a que el comportamiento no produjo perjuicio de carácter patrimonial al Estado y en ejercicio del principio de la proporcionalidad, debe imponerse a la disciplinada XXXX, la sanción disciplinaria mínima para este tipo de casos, consistente en DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive del presente proveído. Lo anterior, como se dispondrá en la parte resolutive del presente proveído.

OTRAS DETERMINACIONES

Atendiendo las pruebas recaudadas y la información aportada al proceso, encuentra este Despacho pertinente compulsar copias de la actuación ante la Fiscalía General de la Nación con sede en la ciudad de Leticia, lo anterior para que esa Entidad en el marco de sus competencias adelante las actuaciones que estime pertinentes. Tramite a surtir por conducto de la Secretaría Técnica de esta Subdirección.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA de la señora XXXXX, identificada con la cédula de ciudadanía número XXXXX, por las conductas consignada como cargo único en el auto número 17406-00027 de fecha 10 de noviembre de 2016; actuar constitutivo de falta disciplinaria gravísima al tenor de lo dispuesto en el artículo 48-1 de la Ley 734 de 2002, en consonancia con el artículo 404 (Concusión) de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), de acuerdo con lo expuesto en el aparte considerativo de esta decisión

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, IMPONER a la señora XXXXX, sanción disciplinaria consistente en DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL DE DIEZ (10) AÑOS PARA OCUPAR CARGOS Y EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS, de conformidad con lo señalado en la parte motiva precedente.

TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la providencia a XXXXX defensora de la disciplinada, en la calle 68 No. 12-40 Consultorio Jurídico Universidad Santo Tomas y a la señora XXXXX, quien puede

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2014-131

ser ubicada en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia, de conformidad con los artículos 103 y 105 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede el RECURSO DE APELACIÓN, en los términos de los artículos 112 y 115 de la Ley 734 de 2002.

QUINTO: En firme la presente decisión, COMUNICAR en la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con el artículo 174 del Código Disciplinario Único.

SEXTO: DAR CUMPLIMIENTO al acápite de otras determinaciones.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,



JORGE ADRIANO MORENO PONCE
Subdirector de Investigaciones Disciplinarias
UAE Agencia ITRC